



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/279/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין אסתי
שחל**

תובע

איציק אלמוג
רח' הפלמ"ח 22, הרצליה

נגד

נתבעים

1. אמנון שלומוף
2. סופיה שלומוף
רח' יותם 14, הרצליה פיתוח

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה בה התבקש להורות לנתבעים לסלק מהגג הצמוד לדירת התובע את מתקן דוד השמש המשרת את דירת הנתבעים בבית המשותף שברחוב הפלמ"ח 22 הרצליה, הידוע כגוש 6536 חלקה 204 (להלן: "הבית"), ולהעתיקו לשטח הגג שמעל חדר המכוניות של הבית.
2. הבית נרשם כבית משותף ביום 12.12.1996. כן נרשם לו תקנון מוסכם במועד האמור. הבית מכיל 4 דירות ששתיים מהן הינן דירות פנטהאוז. האחת ידועה כחלקת משנה 3 לה צמוד גג תחתון וגג עליון המסומנים במסמכי רישום הבית המשותף באותיות ה' ו ז'. השנייה, ידועה כחלקת משנה 4 לה צמוד גג תחתון וגג עליון המסומנים במסמכי רישום הבית המשותף באותיות ו' ו ח'.
3. התובע הוא הבעלים של דירת הפנטהאוז, הידועה כחלקת משנה 4. הנתבעים הם בעלים של דירה בבית הידועה כחלקת משנה 2.
4. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: דוד השמש המשרת את דירת הנתבעים מותקן על הגג העליון הצמוד לדירת התובע, והמסומן במסמכי רישום הבית המשותף באות ח' (להלן: "הגג" או "הגג הצמוד לדירת התובע"); התובע ורעייתו רכשו את דירתם ביום 25.2.2003; בעל הדירה ממנו רכשו את דירתם, מר צביקה מילר, הצהיר בהסכם המכר שנערך עמו כי למיטב ידיעתו אין בדירה כל פגם ו/או מום נסתר, ולא גילה להם כי בגג מותקן דוד שמש המשרת את דירת הנתבעים; דבר הצבת הדוד נודע לתובע באקראי בחלוף מספר שנים עקב נזילת מים שארעה מדוד השמש של הנתבעים אשר הציף את הגג; התובע פנה לנתבעים בדרישה להעתיק את הדוד לגג חדר המכוניות המהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית, אך נענה בסירוב.
5. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: דודי השמש של כל 4 הדירות בבית ממוקמים על הגגות העליונים של דירות הפנטהאוז, ובכלל זה על הגג של דירת התובע, ובאותו המקום בו הונחו לראשונה על ידי הקבלן שבנה את הבית בשנת 1990; מאז הקמת הבית לא שונה מיקום הדודים; התובע היה מודע למצב האמור, ואף דרש מהנתבעים להשתתף בעלות מחצית ההוצאות לאיטום הגג בו מוצב דוד השמש המשרת את דירתם; הנתבעים רשאים להמשיך ולהציב את דוד השמש המשרת את דירתם על הגג הצמוד לדירת התובע וזאת מכוח זיקת הנאה בהתאם לסעיף 94 לחוק המקרקעין, התשכ"ט, 1969 (להלן: "זיקת הנאה"), ויש להורות על רישומה בפנקסי המקרקעין; שטחו של גג חדר המכוניות קטן, ולא ניתן להעתיק אליו את דוד השמש.
6. הצדדים הגישו ראיותיהם, נשמעו עדיהם, וכן הוגשו סיכומים מטעמם. עתה נותר להכריע בתביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/279/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין
דיון והכרעה**

7. אקדים ואומר כי מצאתי לדחות את התביעה. נימוקי יפורטו להלן:
8. הנתבע 1 (להלן: "אמנון") העיד כי מיום שהוקם הבית, וניתן היתר לאכלוסו (טופס 4), 14.2.1990, הותקנו על הגגות העליונים שהוצמדו לשתי דירות הפנטהאוז, ובכלל זה דירת התובע, 4 דודים וקולטי שמש לשימוש הבעלים של 4 הדירות בבית (ראו עותק מטופס 4 צורף כנספח ה' לתצהירו). כן העיד כי זהו המצב עד היום (ראו סעיפים 8 ו-9 לתצהירו).
9. כתימוכין לכך, צירף אמנון את מכתבו של מר צביקה מילר, הבעלים של המגרש עליו נבנה הבית, ומי שמכר לתובע את דירתו בו אישר מר מילר את האמור, ואף הוסיף כי בעת בה מכר את דירת הפנטהאוז לתובע, דודי השמש היו מותקנים על הגגות העליונים שהוצמדו לדירות הפנטהאוז של הבית (ראו נספח ו' לתצהירו של אמנון):

"...אני הייתי הבעלים של המגרש ברח' לייב יפה 24 הרצלייה גוש 6536 ח' 204 שבו נבנה בניין מגורים בן 4 יח'. הבניה הושלמה בינואר 90, ובאותו מועד נמסרו הדירות. חלק לקבלן וחלק אלי. אני מצהיר מהיום שבו הדירות נמסרו לדיירים דודי השמש היו מותקנים על גג הדירות העליונות.

אני מכרתי למר אלמוג (התובע, א.ש.) את הדירה וביום שמכרתי את הדירה היו מותקנים דודי שמש + קולטים על גג הדירות העליונות".

10. כן צירף אמנון לתצהירו את מכתבו של מר אביעם אלקס, מי שרכש מהקבלן את דירת הפנטהאוז הידועה כחלקת משנה 3 אשר אישר את האמור (ראו נספח ו' לתצהירו של אמנון).
11. עדות וראיות אלו לא נסתרו. בחקירתו הנגדית אישר התובע כי דוד השמש קיים על הגג הצמוד לדירתו מיום הקמתו של הבית (ראו פרוטוקול מיום 12.9.2021, שורות 19-20).
12. נוכח האמור לעיל, שוכנעתי שדוד השמש המשרת את דירת הנתבעים קיים על הגג הצמוד לדירת התובע משנת 1990, המועד בו הוקם הבית. היות שאין מחלוקת כי הגג עליו הותקן דוד השמש צמוד לדירת התובע, מוצאת אני להרחיב ולהתייחס לאופיו המיוחד של הבית המשותף טרם שאקבע מסמרות בנוגע לדוד השמש, מושא ההליך.
13. בעניין זה אפנה לדברים שנאמרו ברע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, פד"י (5) 550 בהתייחסו למוסד הבית המשותף:

"...הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה...הוויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין...זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

ובהמשך פסק הדין - "גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס את דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף-אם תרצה; החיים יחדיו- אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת; מצמצם ומצר הוא את תכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף. ובשונן של השופט ויתקין בדיון הנוסף בפרשת סדובסקי בעמ' 736: "בית משותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/279/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

'פנים לו לצד השיתוף ולצד הפרדה שבין השותפים, ואני מייחס חשיבות מיוחדת לצד השיתוף, דהיינו למגבלות שהחיים בצוותא מטילים על כל שותף ושותף.'

14. ואכן זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה המיוחד של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית, ולכן יכול וזכות זו תהיה כפופה לזכויות שימוש או מעבר כלשהן של אחרים בבית. ודוק- בדירות רבות בבתים משותפים עוברת צנרת ביוב וניקוז משותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות כגון דא, בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין (להלן: "חוק המקרקעין") מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע -"אפילו הם בתחומי דירה מסוימת", לאמור, בבית משותף יתכן כי הרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו.

15. כרסום דומה בזכות הקניין בבית משותף קיים גם לגבי חלקים שהוצמדו לדירה. בבתים רבים עוברות בתוך חצרות אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני/צוברי גז ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית. במקרים אחרים מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות על גגות אשר הוצמדו לדירה/דירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר לטיפול באותם מתקנים.

16. נוכח האמור, ובשים לב לכך שדוד השמש הותקן על הגג הצמוד לדירת התובע מיום הקמתו של הבית, סבורה אני כי הבעלים הקודם של דירת התובע, מר צביקה מילר, והתובע כמי שנכנס בנעליו קנו זכויות בעלות בגג אשר כפופות לקיומו של הדוד עליו, ועל כן לנתבעים רשות לעשות שימוש בגג לצורך האמור. ראיה לכך, שהתובע ידע על קיומו של הדוד על הגג ואף הסכים לו מצאתי בכך שהתובע דרש מהנתבעים לשאת בתשלום הוצאות איטום הגג עליו מותקן דוד השמש, מושא ההליך, וזאת אף שאין עוררין כי הגג צמוד לדירת התובע (ראו עדותו של אמנון בסעיף 10 לתצהירו אשר לא נסתרה. כן ראו דרישת התובע לנתבעים לשאת בתשלום הוצאות האיטום, נספח ח' לתצהירו של אמנון). דרישה זו אינה עולה בקנה אחד עם טענת התובע, כי לא ידע על דבר קיומו של דוד השמש, ולכן לא מצאתי לקבלה.

17. שונים הם פני הדברים מאשר מצב בו רכש אדם זכויות בגג נקי, ולאחר מכן הולך אחד מבעלי הדירות בבית ומתקין על אותו גג דוד או כל מתקן אחר אשר ישמש אותו. ברי כי בעל דירה אינו רשאי להתקין מתקנים פרטים על הצמדה שצמודה לדירתו של אחר, ואולם, חצר אשר הוצמדה מלכתחילה כאשר מצויים בה שוחות ביוב, מוני מים משותפים וכיוב' או גג שהותקנו עליו ביום הקמת הבית דודים, הדעת אינה סובלת מתן אפשרות לבעל הדירה לדרוש את סילוקם מהטעם שהדבר פוגע בקניינו.

18. הקמת הבית כשהגג כולל דוד שמש עליו מהווה הסכמה ורשות של בעל הדירה לו צמוד הגג שהדוד יותקן עליו.

19. עתה יש לבחון את השאלה האם רשאי התובע להודיע על סיומה של רשות זו, ולדרוש את סילוקו של דוד השמש מהגג.

האם התובע רשאי לסיים את הרשות?

20. בחוק המקרקעין לא הוסדר מוסד הרשות במקרקעין, אשר הינו יציר הפסיקה. מקורו של מוסד הרשות במקרקעין הוא ב"תורת ההשתק" (ESTOPPEL) שפותחה בדיני היושר האנגליים. השתק נועד למנוע תוצאות בלתי-צודקות, המתחייבות לכאורה מן הדיון, על ידי השתקת המתנגדים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות או עובדתיות, שהן נכונות כשלעצמן (ראו ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4), 27, 34-35).

21. ההשתק הקנייני (estoppel proprietary), מקורו בדיני היושר האנגליים (equity), כפי שיישמו בארץ (ראה: נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", הפרקליט מ"ב (1995), 25-26). זהו אחד מכללי המניעות (estoppel) בדומה לכללי המניעות האחרים, כגון השתק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/279/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכוח מצג (estoppel by representation) והשתק מכח הבטחה (promissory estoppel). להבדיל מן הסוגים האחרים של כללי המניעות, ההשתק הקנייני יכול לשמש חרב ולא רק הגנה. לאמור, ההשתק הקנייני מקים עילת תביעה ואינו משמש רק טענת הגנה (ראה: נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", שם, 31).

22. בדומה לכללי המניעות האחרים, ההשתק הקנייני מבוסס על הציפיה שיצר בעל המקרקעין בהתנהגותו אצל בר הרשות, כאשר בר הרשות שינה את מצבו לרעה על בסיס התנהגות זו. לעניין הציפיה כתבה פרופ' זלצמן במאמרה כי: **"הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך"** (נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", שם, 30).

ובמקום אחר בדונה בהשתק הקנייני או הרשות מכוח ההשתק כתבה פרופ' זלצמן: **"הסתמכותו של מקבל הרשות על הציפיה שיצר אצלו בעל המקרקעין ושינוי מצבו לרעה, ישפיעו על המשך קיומם של יחסי הרשות ויכולת סיומם באורח חד צדדי על ידי בעל המקרקעין"**. (נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", עמ' 42)

23. אמנון העיד כי רכש את דירתו בשנת 1999 ביודעו כי מותקן על הגג הצמוד לדירת התובע, דוד שמש המשרת את דירתו (ראו פרוטוקול מיום 12.9.2021, עמ' 2, שורה 31, וכן עמ' 3, שורות 5-6). עדותו זו לא נסתרה. בנסיבות אלו, ובשים לב לכך, שבמשך שנים כה רבות, לא ננקטו כנגד הנתבעים צעדים כלשהם להסרת הדוד, ובשים לב לכך שהנתבעים אף נשאו בהוצאות איטום הגג עליו מותקן דוד השמש בהתאם לדרישת התובע (ראו סעיף 10 לתצהירו של אמנון וכן העתיקי המחאות בדבר התשלום, נספח ח' לתצהירו אשר לא נסתרו), נוצרה אצל הנתבעים ציפייה והסתמכות להמשיך לעשות שימוש בדוד השמש המותקן על הגג.

24. הסרת דוד השמש מהגג תחייב את הנתבעים בהוצאות כספיות נכרות הכרוכות ברכישת דודי חשמל התקנתם ותשלום חשבונות חשמל גבוהים יותר עקב היעדר ניצול משאב השמש לחימום המים בדירתם. בהקשר זה ייאמר כי גם לא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בטענת התובע כי ניתן להעתיק את דוד השמש לגג המשותף שמעל חדר המכונות. יתירה מכך, אמנון העיד כי שטחו של הגג האמור "הוא סך הכל 1.5 מ' על 2 מ' ", ואינו גדול דיו על מנת להעתיק את דוד השמש לשטח זה (ראו פרוטוקול מיום 12.9.2021, עמ' 3, שורות 21-22). עדותו זו לא נסתרה.

25. לאור האמור אינני מוצאת לאפשר לתובע לבטל את הרשות שניתנה לנתבעים לעשות שימוש בדוד השמש המשרת את דירתם, והמותקן על הגג הצמוד לדירת התובע. נוכח התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי לדון בטענת הנתבעים לקיומה של זיקת הנאה. לא הוגשה תביעה שכנגד להורות על רישומה של זיקת הנאה, וממילא אין בסמכות המפקח על רישום מקרקעין להורות על רישומה.

26. בסעיף 3 (א) לתקנון המוסכם החל על הבית נקבע כדלקמן: **"בעלי דירות 204/3 - 204/4 שאליהן צמוד הגג (דירות הפנטהאוז, א.ש.) יהיו זכאים לבנות על שטחי הגגות הצמודים לדירתם כל תוספת בניה שהיא בכפוף לקבלת היתר מאת הרשויות המוסמכות כדין....."**

27. בסעיף 3 (ד) לתקנון המוסכם נקבע כי **"גג או גגות וקירות חיצוניים אשר ייווצרו כתוצאה מבניה כאמור לעיל לא ייחשבו כרכוש משותף ויהיו צמודים לחלקת משנה שבה בוצעה הבניה"**.

28. בנסיבות אלו, הנתבעים יהיו רשאים להותיר את דוד השמש על הגג הצמוד לדירת התובע כל עוד לא יהיה בידי התובע היתר בניה כדין לבנייה על הגג האמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/279/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. בהינתן שיהיה בידי התובע היתר בניה כדין לבניה על גג זה, כולו או מקצתו, יעתיק התובע על חשבונו את דוד השמש לשטח הגג עליו לא נעשית בניה או אל הגג החדש שיוצר כתוצאה מהבניה לפי העניין.

30. התביעה, אפוא, נדחית. התובע ישלם לנתבעים סך של 3,000 ₪ עבור הוצאות ההליך. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, 27 בדצמבר 2021, כג' בטבת תשפ"ב. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה